

1502050-10.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... o C. Superior Tribunal de Justiça:

"DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato - SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502050-10.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502050-10.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON RODRIGUES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Marques de Jesus

Vistos.

ROBSON RODRIGUES DA SILVA e GABRIEL DA SILVA RÁGIO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, II, 'j', do Código Penal, porque no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 16h20, na Rua Trinta e Dois, altura do nº 114, Jd Vassouras II, cidade e Comarca de Francisco Morato, agindo em concurso entre si, para fins de tráfico, traziam consigo 62 (sessenta e duas) porções de "maconha" (cannabis sativa L.), com peso líquido aproximado de 1.434.16g (mil, quatrocentos e trinta e quatro gramas e dezesseis centigramas); 101 (cento e uma) porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 93.22g (noventa e três gramas e vinte e dois centigramas); e 35 (trinta e cinco) porções de "crack", com peso líquido de aproximadamente 5,11g (cinco gramas e onze centigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 1/4).

As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas (fls. 69/72).

Notificados, os réus apresentaram defesas (fls. 168/173 e 202/207) e a denúncia foi recebida (fls. 216/220). Citações às fls. 162/163 (Robson) e 164/165 (Gabriel).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (fls. 274/275), uma testemunha do Juízo (fls. 276) e os réus interrogados (fls. 277/278). Mídias arquivadas.

Em debates o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia, observando a fixação de pena base acima do mínimo legal, sem possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da lei nº 11.343/06 e a ser cumprida em regime inicial fechado, a reincidência de Robson e a agravante do estado de calamidade pública (fls. 271/273 e 293). A Defesa de Robson manifestou-se pela absolvição, com amparo no artigo 386, V e VII, do CPP e, sendo o caso de condenação, pela aplicação do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade (fls. 294/298). A Defesa de Gabriel, por sua vez, reiterou o pedido de inépcia da inicial e pleiteou a absolvição ou, em caso de condenação, a detração da pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 299/301).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Afasto, por primeiro, a questão preliminar trazida pela Defesa do réu Gabriel.

Em que pese o entendimento da esforçada Defesa, nada há de ilegal nas provas decorrentes do ingresso dos policiais na residência do acusado sem mandado de busca e apreensão, em suposta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

O delito de tráfico de drogas classifica-se como um crime permanente, daqueles cuja consumação se protraí no tempo, de sorte que, antes mesmo da abordagem, o réu já guardava e mantinha os entorpecentes sob sua posse, justificando a sua prisão em flagrante, daí porque se dispensa até mesmo mandado de busca e apreensão para o ingresso de agentes da autoridade na residência da traficante.

Prescindível o mandado judicial para o ingresso no domicílio quando há consentimento do proprietário ou morador, bem como quando referida apreensão decorre de uma situação de flagrante delito, tal como na hipótese.

Neste sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da

Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (STF, Tribunal Pleno, RE 603.616 - Tema 280 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, data do julgamento 05/11/2015, publicação 10/05/2016) – grifos nossos

"(...) O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência cuja urgência em sua cessação demande ação imediata é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. (...)". (Superior Tribunal de Justiça, HC nº 598.051/SP, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2.3.2021, DJe 15/3/2021) – grifos nossos

"APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Preliminar – Preliminar – Nulidade da prova em razão da invasão de domicílio – Inocorrência – Além da permissão de ingresso, tratando-se de crime permanente e, portanto, em andamento, o ingresso no local não é ilegal – Preliminar rejeitada - Mérito – materialidade e autoria bem delineadas que não foram objeto do recurso – condenação de rigor – Dosimetria – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Confissão compensada com a reincidência na segunda fase da dosimetria – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido – Preliminar rejeitada e Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1500752-05.2020.8.26.0548; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021) – grifos nossos

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recursos defensivos. PRELIMINAR. Prova ilícita não caracterizada. Prescindibilidade de mandado judicial por se tratar de flagrante em crime permanente. Suposta ofensa ao contraditório que se confunde com o mérito. Rejeição. ABSOLVIÇÃO. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. DOSIMETRIA. Penas mantidas. Inaplicabilidade do redutor do § 4º e do CP, art. 44. Regimes preservados. DESPROVIMENTO." (TJSP; Apelação Criminal 1502188-85.2020.8.26.0196; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021) – grifos nossos

"Cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão do traficante em sua residência, durante o período noturno, não constitui prova ilícita. Desnecessidade de prévio mandado de busca e apreensão" (RT 832/474).

"Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos das partes. PRELIMINAR. Alegação de ilicitude da prova em decorrência de maltrato ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Quadro não configurado. Prova oral que dá conta da existência de autorização ao ingresso na residência. Circunstâncias concretas do feito que sinalizam, inclusive, para um cenário de fundada suspeita da prática de

delito permanente, o que se prestaria a justificar o ingresso dos policiais. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação 2. As circunstâncias do caso desnudam um cenário incompatível com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 3. Absolvição do acusado quanto à imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 33, parágrafo 1º, e no artigo 34 da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. 4. Sanções que comportam alteração. Circunstâncias concretas do caso que impõem o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 5. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Apelo defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial acolhido." (TJSP; Apelação Criminal 1504169-36.2019.8.26.0536; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021) - grifos nossos

Tem-se, na espécie, que o réu foi surpreendido, após indicação de cães farejadores, enquanto mantinha sob guarda significativa quantidade de drogas ("maconha"), destinada exclusivamente ao tráfico ilícito, em situação de evidente permanência a autorizar a prisão em flagrante delito. Sabido que o delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de conteúdo variado ou misto alternativo, bastando a realização de qualquer verbo do tipo penal para sua configuração, independentemente da demonstração de atos próprios da mercancia espúria. Oportuno e relevante anotar, além disso, que é incogitável a nulidade da prisão em flagrante, porquanto a atuação da Polícia Militar se deu de maneira legítima, em razão de fundadas razões e do evidente estado de flagrância do acusado a legitimar a atuação dos agentes públicos.

Vale destacar que as circunstâncias que antecederam a entrada dos agentes de segurança no domicílio evidenciaram, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tal diligência e a prisão em flagrante do suspeito. A diligência foi encetada após a fundada suspeita dos policiais, em razão da fuga e do apontamento feito pelos cães. Estavam diante da prática de crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, hipótese em que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, excepciona o ingresso na casa sem o consentimento do morador, por se tratar, frisa-se, de situação de flagrante delito.

Não consta que os agentes públicos tenham atuado de forma arbitrária ou violenta, tampouco violado o domicílio. Em função disso, e tendo-se em conta que havia fundada suspeita da ocorrência do ilícito penal (suspeito correu ao visualizar a viatura e os cães da polícia apontaram para a sua residência), conclui-se que a diligência não foi ocorrência infundada ou aleatória, não havendo que se falar em ilegalidade na ação dos agentes públicos, nem em ilicitude da prova amealhada, por inexistência de mandado de busca prévio, ou por estar caracterizada a invasão domiciliar. O fato de os policiais terem ingressado no imóvel sem mandado de busca e apreensão não torna ilícita a prova obtida.

No mais, a tese de que os policiais agrediram o acusado mostrou-se afastada das demais provas, em especial dos laudos de fls. 281/282 e 285/286, e eventual agressão ao corréu será apurada em expediente próprio, nada alterando a comprovação do delito nestes autos tratado.

No mérito, à luz das provas carreadas aos autos, a pretensão inicial merece prosperar.

A materialidade restou comprovada ante o auto de prisão em flagrante (fls. 5/10), boletim de ocorrência (fls.11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 22), laudo de constatação provisória (fls. 38/44), além do exame químico-toxicológico de fls. 268/270, que constatou as presenças de tetrahidrocannabinol (THC) e de cocaína nas amostras analisadas.

A autoria também é certa.

Perante a autoridade policial, o corréu Gabriel disse que tinha dois mil reais em entorpecentes e que os recebeu como parte de pagamento de uma dívida. Iria consumi-los (fls. 9). Em Juízo contou que estava com seu pai "mexendo na fossa" e sua esposa saiu. Viu a viatura parando e se assustou por estar com droga para consumo no bolso. Correu e bateu na janela do Robson, pois ele estava "assinando". Correram. Os policiais entraram e bateram. Eles entraram na sua casa e pegaram duas mochilas, sendo uma de sua filha e outra sua, pois tinha chegado da praia. Tinha 20 ou 25g de cocaína. Não tinha dinheiro. Robson mora no mesmo quintal. Ele correu também. Quando chegou na delegacia viu outra viatura chegar com mochila e jogar na viatura que estava. Não viu drogas. Embalagens plásticas usadas estavam em cima do armário. "Não tinham muitas, no máximo 30". Os policiais já o tinham abordado antes e o liberado. Sobre suas declarações de fls. 9 confirmou que recebeu a droga. Não viu dinheiro. Tem 25 anos de idade, tem duas filhas menores de idade, mora em casa própria, nunca foi preso ou processado criminalmente. Esclareceu que foi chamar o Robson, que mora no mesmo corredor, porque ele tem passagem e quis avisá-lo da chegada dos policiais. Desconhece o motivo dos policiais "plantarem droga". Passou por IML. Robson passou por hospital, pois quebrou o nariz. Não tinha dinheiro nem celulares. Policiais não pediram autorização para entrar na sua casa. O portão estava aberto. Os policiais perguntaram de droga e revólver e falaram que só parariam de bater quando falassem. Tinha dois policiais e um "lá em cima". Depois chegaram outras viaturas. Trabalha na "99" e está montando uma pizzeria (fls. 277).

Durante a fase policial, o corréu Robson narrou que fugiu dos policiais por medo, mas que não tinha nenhuma droga consigo ou no interior de sua residência (fls. 10). Em Juízo contou que estava dentro de casa porque o pai do Gabriel estava arrumando a tubulação do banheiro. Foi avisado por Gabriel de que os policiais estavam invadindo a casa. Ficou com medo e saiu correndo, "não estava com nada". Foi algemado, torturado, conduzido para a viatura e depois para a Santa Casa. Nada foi encontrado em sua casa. Estava na delegacia quando outras viaturas chegaram com a "bolsa de drogas". Foi o "policial japonês" que entrou na casa e o outro o agrediu. Montou uma pizzeria, depois um bar e neste bar já havia sido abordado pelos policiais. Viu apenas a bolsa preta dentro da viatura e não viu o que tinha dentro. Estava trabalhando com tabacaria e fazendo bico de pintura. Ganhava aproximadamente mil e trezentos reais. Tem dois filhos menores, mora na casa do enteado. Possui condenação "por 157 em 2014 e um usuário em 2004, só". Indagado disse que fugiu pela forma que os policiais ingressaram na residência, dizendo que iriam arrancar a criança do ventre da mãe gestante, dizendo que iriam matar todo mundo. Foi torturado por cinco minutos, ficou ensanguentado e com a camisa rasgada (fls. 278).

Olavo Watanabe de Mendonça, policial militar que participou da ocorrência, afirmou que estava em patrulhamento pelo município e na referida rua visualizaram os dois em frente a um portão. Eles correram sentido a um matagal. Havia entorpecente e um deles disse que devia um carro para o PCC e estava conseguindo dinheiro através do tráfico. Retiraram os dois e encontraram entorpecentes. Com ajuda do canil encontraram mais drogas. Foram conduzidos para a delegacia. Eles estavam juntos e correram juntos para dentro do portão em direção ao matagal nos fundos da residência. Primeiro encontraram drogas, acreditando que cocaína e maconha, dentro de uma mochila. A mochila estava com um e depois o canil encontrou mais droga no quarto de um deles. No momento da abordagem um deles soltou a mochila. O mais magro que disse que devia dinheiro ao PCC. O da "esquerda de óculos" que devia para o PCC e o "da direita disse que iria vender". Não se recordou qual dos réus estava com a mochila. Esclareceu que o matagal era junto da residência, ao final do corredor, como se fosse um quintal. Os réus foram presos nesse matagal. Lembrou-se da mochila, mas não do momento em que um deles soltou. Tinha vários celulares na mochila. Não se recordou de dinheiro. Tinha vários quartos e com o apoio do canil, ao passar pelo corredor em direção ao matagal, os cachorros apontaram um quarto onde havia mais droga. Um deles morava lá, acreditando ser o que não estava com a mochila. Um disse que morava lá e que devia dinheiro ao PCC. O outro disse que

buscava droga ali para vender. Não se lembrou da quantidade e tipos de droga, mas havia entorpecentes no cômodo, em local de fácil visualização. Acreditou que houvesse eppendorfs vazios, acreditando também fossem iguais aos das drogas embaladas apreendidas. Era um patrulhamento de rotina. Não se recordou do horário da ocorrência. O pai de um deles estava no local e falou que era o quarto do filho e o próprio morador confirmou. Não entraram na casa antes da abordagem. Primeiro os réus foram alcançados e depois pegou a mochila. Viram eles dispensando a mochila, só não se lembrando do momento exato, se antes ou depois de entrar o matagal. Na ocorrência estavam em três policiais, provavelmente (fls. 274).

Na mesma esteira o depoimento do também policial militar Wallace Gercino de Moura Silva, informando que estavam em patrulhamento de força tática. Um deles estava com uma mochila e se assustou ao visualizar a viatura. Deixou a mochila e ocorreu para um matagal. Na mochila tinham drogas, celulares e dinheiro. Com o apoio do canil encontraram em um quarto mais drogas. Um disse que revendia para pagar uma dívida e o outro que morava em um quarto nesse corredor. Não conhecia nenhum deles antes dos fatos. Reconheceu os réus presentes em audiência. O da "esquerda" disse que morava no quarto. Ambos estavam saindo da casa juntos. Visualizaram com a mochila, eles correram e no final do corredor tinha um terreno baldio, uma mata. A mochila estava dentro da mata. O "sem óculos" disse que pegaria droga para revender. Pediram apoio do canil e os cães indicaram um quarto. Tinha uma mochila em cima da cama com eppendorfs vazios ("eram muitos") e maconha. O pai e a irmã estavam no momento e confirmaram ser o quarto de um deles. O matagal ficava no fundo do terreno da casa em que eles estavam na frente. A droga encontrada estava em "saco de geladinho". Os eppendorfs eram de plástico. O pai que estava no local acompanhou quando já estavam dentro da casa. Confirmou que a primeira mochila, que estava na mão do "da direita", foi encontrada na mata. Foi uma abordagem de rotina, em patrulhamento. O motivo da abordagem foi que ao verem a viatura eles pararam, se assustaram. Foram abordar para ver o que tinha na mochila e eles então correram. A mochila encontrada era aquela que estava na mão de um deles. Não perderam de vista. Entraram somente no cômodo indicado pelos cães. Antes do canil chegar o pai mencionou que não queria que entrassem no local, mas informou que se os cães encontrassem algo teriam que entrar (fls. 275).

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Há de se levar em conta que os acusados e os policiais militares não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-los leviana e gratuitamente.

Ademais, a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1158921/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julg. 17/05/2011, DJe 01/06/2011);

"O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional" (TJSP, RT 752/586);

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275);

"Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" (TJMG, RT 604/407).

Vanessa Vieira da Silva, ouvida como testemunha do juízo, pouco acrescentou. Disse conhecer os acusados do bairro Jd Vassouras II há pouco mais de um ano. Os dois moram na Rua 32, sem saber identificar as respectivas casas. Mora na rua "de cima". Desconhece o motivo da prisão. Estava na rua no dia. Era por volta de "3 e pouco da tarde". Estava chegando na casa da irmã do Gabriel, sua conhecida. Os policiais estavam no portão e desceram. Cerca de 5 min depois eles voltaram com os dois. Eles ficaram na viatura e outros policiais ficaram no local. Chegaram mais viaturas. Eles entraram e depois voltaram com saco preto e uma mochila. Não vi o que tinha dentro. A irmã do Gabriel mora ali e não soube dizer se ele também. Não soube dizer se usam entorpecentes. Gabriel trabalha de "99" e o Robson não soube dizer o que faz (fls. 276).

A partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório.

E, não demonstrou a Defesa eventual motivo que os policiais militares teriam para mentir em juízo deixando, assim de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura do trabalho policial. Nesse sentido:

"PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78).

As Defesas tentam, em vão, diminuir o valor dos depoimentos dos policiais, o que não se sustenta diante do quadro probatório existente e dos elementos de convicção formados. Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares

presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos.

Dentro desse quadro, os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, repita-se, foram harmônicos e convergentes, levando à certeza da autoria.

Sendo assim, a variedade, a quantidade e nocividade das drogas apreendidas, a forma como embaladas, bem como o depoimento seguro prestado pelas testemunhas, levam à certeza de que os réus traficavam drogas na ocasião.

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que as simples condutas dos réus, consistentes em “trazer consigo” as substâncias entorpecentes, já são suficientes para caracterização do delito:

“Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP – Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 – 5ª Câmara Criminal - Campinas – v.u. – j. 03.09.09 – Rel. Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663);

“Não é indispensável à prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido” (RT 729/542);

“Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita”. (TJ/SP – Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 – 14ª Câmara Criminal - v.u. – j. 11.03.10 – Rel. Des. Fernando Torres Garcia). Ressalta-se que a considerável quantidade e variedade de entorpecente, além da forma como se deu sua apreensão demonstram a traficância e não autorizam eventual classificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06):

“DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade - Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta.” (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09).

E o fato de o acusado Gabriel afirmar que é usuário de drogas não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, sendo, repita-se à exaustão, a condenação de rigor. Vale destacar, ainda, que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante:

“(...) a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício,

de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra." (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP 101/498);

"Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra" (TJSP; 9.^a Câmara Criminal, Ap. n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, j. em 31.03.2016);
"Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados" (RT 411/104).

Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de não desprezível quantidade de substância entorpecente em poder dos agentes, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito, e não ao uso próprio.

Destarte, comprovadas as autorias e a materialidade, inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, amoldando-se a conduta praticada pelos réus à figura típica prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar individualmente a pena:

Sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal e em observância ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que autoriza que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria a natureza do entorpecente, a quantidade, a personalidade e a conduta social do agente, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal (v.g. STF, HC nº 96.655, rel. Min. Cármen Lucia; STF, HC nº 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC nº 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 235.524, rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC nº 223.447, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 179.086, rel. Min. Gilson Dipp). No mesmo sentido:

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda de piso acima do mínimo legal, em razão da natureza e a excessiva quantidade do estupefaciente apreendido, encontra-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado.
[...] 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017);

O réu Robson, na hipótese, foi localizado com "crack" e cocaína, entorpecentes de alto poder viciante, que causam dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja uma maior reprimenda, pois seria desarrazoado punir aquele que vende "maconha" na mesma medida daquele que vende entorpecente altamente viciante, que além de causar um impacto muito maior na saúde do usuário, ainda repercute na sociedade e na família, somado ao fato de corroborar com a prática delitiva daqueles que não possuem condições financeiras de sustentar o vício.

Segundo o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, "A Lei de Drogas baseia-se,

principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 378)

No mesmo sentido, defende Ricardo Brasileiro de Lima que "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (in Legislação criminal especial comentada, 2ª edição, JusPODIVM, 2014, p. 787).

Registre-se que a cocaína é considerada um dos entorpecentes mais nefastos e viciantes, o que traz maiores danos à saúde pública, sendo de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser proporcional à quantidade e natureza.

Assim, ponderando tal circunstância (natureza), fixo a pena-base com o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Com relação a Gabriel, localizado com grande quantidade de maconha, sendo de rigor também a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser proporcional à quantidade. Assim, igualmente fixo a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Quanto à fração a ser aumentada, vale destacar não haver previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STJ, AgRg no REsp nº 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

Prosseguindo, deve ser reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, alínea "j", do Código Penal, na medida em que o crime foi cometido durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), quando já estava decretado o estado de calamidade pública, com recomendação do isolamento social e outras medidas públicas (Decreto Estadual nº 64.879/20 e Decreto Legislativo nº 6/2020), o que reduz a vigilância.

A prática de crime em cenário no qual toda a população passa por privações e incertezas e em meio a diversas recomendações de recolhimento domiciliar e restrição de atividades de toda ordem é ainda mais reprovável e merece resposta penal diferenciada. A situação atualmente vivida é excepcional e, sem dúvida, do conhecimento de todos. Além disso o réu Robson é reincidente (fls 53/54), motivo pelo qual aumento a pena dele em 1/3 (um sexto), estabelecendo-a em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Primário, a pena de Gabriel fica acrescida de 1/6 (um sexto), fixando-a em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. APELO MINISTERIAL. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "J", DO CÓDIGO PENAL, E DE AFASTAMENTO

DO PRIVILÉGIO, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, valoradas como negativas as circunstâncias relacionadas à natureza da droga (cocaína, acondicionada na forma de tijolos) e do seu transporte entre cidades. Na segunda etapa, pedido ministerial acolhido, para reconhecimento da agravante da prática de crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, "j", do CP). Prática do crime durante a pandemia de COVID-19. Lei não prevê nenhuma condicionante finalística ou modal para que a agravante incida. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, as penas ainda foram reduzidas em 1/10, dada a preponderância da atenuante (art. 67, CP). A quantidade dos entorpecentes apreendidos (quase dois quilogramas de cocaína) e seu alto valor no comércio clandestino de entorpecentes demonstram envolvimento do apelado em atividades criminosas, impedindo, portanto, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o qual fica afastado. Penas redimensionadas para 5 anos e 3 meses de reclusão e 524 dias-multa. REGIME PRISIONAL. Imposição do regime inicial fechado, ante a pena concretizada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal), a par da gravidade concreta do delito praticado. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabível a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena concretizada, Recurso ministerial provido para, afastado o privilégio e reconhecida a agravante do art. 61, II, "j", do CP, redimensionar as penas do apelado, bem como fixar-lhe o regime inicial fechado." (TJSP; Apelação Criminal 1522780-54.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021) – grifos nossos

Na terceira fase não é o caso de incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ou seja, do reconhecimento do crime de "tráfico privilegiado". Restou demonstrado que o réu trazia consigo elevada quantidade de entorpecentes (mais de 1 quilo de drogas), a indicar um acentuado envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Além disso, é reincidente e não demonstrou o exercício de atividade lícita. Quadro, pois, a desnudar que se trata de pessoa dedicada às atividades criminosas.

Enfim, havendo indícios do envolvimento dos acusados com a criminalidade, descabido o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, valendo trazer à colação, como já se decidiu, que a conduta social dos réus, a quantidade e a natureza do entorpecente, além das circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa (RHC nº 116.926/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em 20.8.2013; HC nº 116.541/ES, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.6.2013; HC nº 98.366/MG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.2.2010).

Robson é reincidente e, ainda que Gabriel seja primário, foi surpreendido com grande quantidade de droga (mais de 1kg) a indicar um acentuado envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Além disso, não demonstrou o exercício de atividade lícita, quadro, pois, a desnudar que se trata de pessoa dedicada às atividades criminosas. Enfim, havendo indícios do envolvimento dos acusados com a criminalidade, descabido o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido o C. Superior Tribunal de Justiça:

"DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. No caso em análise, com base na grande quantidade de drogas

apreendidas, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 3. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018). 4. Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos já tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria penal, para exasperar a pena-base, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa, para aferir a traficância habitual e, conseqüentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006." (AgRg no HC 499936 Rel. Min. Jorge Mussi julg. 25/06/2019 publ. 01/07/2019).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA NORMATIVIDADE REGENTE. QUANTUM DE PENA A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional" (Quinta Turma, AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020).

Estas penas tornam-se definitivas, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento e de diminuição.

Os valores dos dia-multa devem ser calculados nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, sendo fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a situação econômica dos acusados.

Além disso, não se pode olvidar a natureza da infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua conduta, razão pela qual os réus deverão cumprir suas penas em regime inicialmente fechado:

"TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; 6ª Câmara de Direito Criminal; AP 0057527-71.2011.8.26.0050; Relator Marco Antonio Marques da Silva, data do julgamento: 27/06/2013).

Vale lembrar que embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 (HC 111.840/ES), a r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo eficácia erga omnes e nem efeito vinculante.

E, não sendo o caso de reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme justificado, não há que se falar em aplicação da determinação proferida no Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP, do C. Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), que determinou a fixação do regime aberto em relação aos presos que "se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses,

em regime fechado)", estabelecendo, dentre outras determinações, que "aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena" (grifo nosso).

As condições pessoais dos acusados não são idênticas às daqueles para os quais se determinou a concessão de regime inicial aberto, não se mostrando socialmente recomendável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (artigo 44, III, do Código Penal).

Ainda que assim não fosse, impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante do montante da pena, da reincidência e também da gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, somando um total líquido aproximado de 1.532,7g (fls. 38/44), o que justifica a não substituição da reprimenda (STJ, Quinta Turma, HC 24914/SP, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 14/04/2013):

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - 11,2G DE COCAÍNA, 179,1G DE MACONHA E 554ML DE LANÇA-PERFUME - PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "j" - IMPOSSIBILIDADE - O NECESSÁRIO ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS GARANTIU, POR INFELIZ VIA TRANSVERSA, O ANONIMATO E A IMPUNIDADE DE USUÁRIOS E TRAFICANTES - AGRAVANTE MANTIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA A INDICAR QUE O ACUSADO, CONQUANTO PRIMÁRIO, FAZ DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA - REGIME FECHADO ADEQUADO - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO QUALITATIVO DA PENA - IMPROVIMENTO DO RECURSO" (TJSP; Apelação Criminal 1514354-53.2020.8.26.0228; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020) - grifos nossos

Ademais, tais benefícios são incompatíveis com a finalidade da Lei nº 8.072/90, que dá tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e assemelhados e que prevê, dentre outras hipóteses, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da sanção imposta ao protagonista de delitos deste jaez.

Pelo mesmo motivo e diante da persistência dos requisitos que mantiveram a prisão cautelar durante o curso do processo, os acusados não poderão recorrer em liberdade. Assim, deverão manter-se recolhidos para poder recorrer, até porque seria um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenou. Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na prisão em que se encontram, bem como guias de recolhimento provisória, encaminhando-as, com as peças obrigatórias, ao Juízo da Execução competente.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar ROBSON RODRIGUES DA SILVA e GABRIEL DA SILVA RÁGIO, qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, II, j, do Código Penal, fixando-lhes, respectiva e individualmente, as penas privativas de liberdade de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

Em observância ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que os réus encontram-se presos preventivamente a pouco mais de seis meses, contudo, não há elementos nos autos - principalmente os subjetivos - para

eventual colocação em regime mais benéfico, que fica condicionada à demonstração de que ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, bem como à verificação de que não se encontra presos, provisória ou definitivamente em razão de outro processo.

Eventual progressão, portanto, quando cabível, deverá ser verificada em sede do Juízo das Execuções Criminais, a ele competindo proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos artigos 66, III, "a" e 111, ambos da Lei nº 7.210/84:

"Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria." (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467